EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU/SC

Ref. Ação Civil Pública 5012227-71.2018.4.04.7205/

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB), organização indígena que representa os Povos Indígenas do Brasil, com escritório de representação localizado no SDS, Ed. Eldorado, sala 104, Brasília – DF – CEP 70.392-900, neste ato representada por seu Coordenador Executivo **KLEBER KARIPUNA** (art. 231 e 232 da CF/88), brasileiro, indígena do Povo Karipuna, portador do CPF n. 661.587.612-49 e da Cédula de Identidade RG n. 3416084 SSP-PA; residente e domiciliado no Condomínio Morada dos Nobres, Sobradinho, Brasília/DF, vem, com máximo respeito, por suas advogadas e advogados abaixo assinados, conforme instrumento de procuração, vem, respeitosamente perante o juízo e por intermédio de seus procuradores, requerer ingresso no feito em litisconsórcio necessário.

1. Relatório

Trata-se de Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença contra a União e o Estado de Santa Catarina em razão da condenação dos entes públicos à realização de diversos serviços de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente.

As últimas medidas adotadas nos autos voltavam-se à intimação do IPHAN (evento 231) e da FUNAI (evento 230) para que se manifestassem,

respectivamente, sobre a existência de um sítio arqueológico na área das barragens e sobre a manutenção de conflitos indígenas envolvendo aquele local.

Nesse contexto, em sede de plantão judicial (evento 233) e sob argumento de iminência de desastre natural, foi requerida, pelo Estado de Santa Catarina, a concessão de tutela cautelar a fim de assegurar o acesso à barragem norte, localizada no Município de José Boiteux e dentro da Terra Indígena Laklaño Xokleng, a fim de permitir a retomada da capacidade operacional da barragem pelo ente público, juntamente com pedido para suporte da União no oferecimento de forças policiais.

O Ministério Público Federal (evento 242) opinou favoravelmente ao pleito do Estado de Santa Catarina por entender estarem presentes tanto a plausibilidade do direito alegado, plasmado na obrigação do requerente de assegurar o eficiente cumprimento do serviço público de controle e prevenção de cheias, bem como o perigo na demora, uma vez que sobejam nos autos dados sobre o iminente desastre natural em questão, demonstrando o grave, atual e concreto risco à vida, à saúde, ao patrimônio e a diversos outros direitos fundamentais de grande parcela da população do vale do Rio Itajaí e adjacências.

Em despacho proferido pelo juízo (evento 246) houve concessão da pleito cautelar realizado seja assegurado ao Estado de Santa Catarina, bem como o acesso e ingresso na Barragem Norte de José Boiteux/SC, permitindo-se a retomada e a regular operação de sua capacidade operacional pelo ente público. Competiu, na decisão, à União, o suporte operacional necessário, inclusive com o uso de forças policiais.

Igualmente, na determinação judicial constou a obrigação de que o Estado de Santa Catarina adotasse todas as medidas necessárias a debelar os riscos e danos decorrentes da operação da Barragem José Boiteux a todos os residentes no

local, inclusive fornecendo barcos para o seu resgate, água potável e víveres aos atingidos.

O Ministério Público Federal, então (evento 253) informou a realização de acordo entre as lideranças da Comunidade Indígena Laklãnõ, mediante o Cacique-Presidente daquela Terra Indígena; o Prefeito de José Boiteux, Adair Antônio Stolmeier; a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, na pessoa da Sra. Elna Fátima Pires de Oliveira e o Secretário da Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, Jerry Comper; no qual foram entabulados os termos e condições nos quais a comunidade indígena autoriza a operação da Barragem José Boiteux (cópia anexa).

Dessa forma, o *Parquet* Federal requereu a determinação ao Estado de Santa Catarina para que adotasse todas as medidas necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas no acordo em tela, com a máxima urgência, com a desobstrução e melhoria das estradas; equipe de atendimento de saúde em postos 24 horas; três barcos para atendimento da comunidade; ônibus para atendimento da comunidade até a cidade; água potável na aldeia; fornecimento de cestas básicas e o cumprimento do combinado para que fossem construídas novas casas para as famílias com moradas sobremesas, em local seguro e longe do nível do rio.

Logo, o juízo acolheu (evento 257) o requerimento formulado pelo Ministério Público Federal para que com o implemento da tutela cautelar deferida no evento 246 o Estado de Santa Catarina adote todas as medidas necessárias a debelar os riscos e danos decorrentes da operação da Barragem José Boiteux a todos os residentes no local.

Por ocasião de manifestação do Ministério Público Federal (evento 270) com gravíssima notícia sobre agressão aos povos indígenas da região por forças policiais, bem como a retirada de cestas básicas da aldeia, com a consequente

inexistência de água potável e alimentos aos povos tradicionais, o que ocasionou conflito e quebra do acordo firmado, foi designada audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2023 (evento 272).

Nesta senda, em audiência realizada com a presença do juízo, do MPF, da AGU, do Estado de Santa Catarina, da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas e de lideranças locais, ficou acordado o seguinte:

> 1. Inicialmente, considerando a anuência pelo Estado de Santa Catarina quanto às condicionantes inscritas na decisão proferida no evento 256, em favor da Comunidade Indígena, foi determinada a elaboração de cronograma de sua efetivação com relação ao item "1" (Desobstrução e melhoria das estradas) e 7 (construção de novas casas para as famílias afetadas pela retomada da operação da barragem, em especial o fechamento de suas comportas), a ser elaborado no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo, desde já, da manutenção e observância do fiel cumprimento dos demais itens (2, 3, 4, 5 e 6). 2. Com relação à utilização da força policial, o Estado de Santa Catarina está de acordo com a utilização de efetivo proporcional da Polícia Militar, observada a atuação subsidiária e sob a coordenação da Polícia Federal nos próximos 10 (dez) dias, a contar do presente ato. 3. Cumprirá ao Ministério Público Federal a adoção das medidas necessárias visando à apuração dos fatos relacionados ao confronto publicamente noticiado entre a força policial e indígenas no cumprimento das determinações constantes dos eventos 246 e 256. 4. Cumpre aos indígenas, representados nesta audiência por seus líderes, a observância da determinação judicial que assegura a prestação do serviço público pelo Estado de Santa Catarina na operação da Barragem Norte de José Boiteux/SC. 5. Defiro o requerimento da FUNAI. Caberá ao Estado de Santa Catarina, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a juntada de laudo ou estudo técnico que permita constatar a segurança e as consequências do procedimento de fechamento das comportas em relação à Comunidade Indígena Laklãnõ Xokleng afetada e em relação aos demais munícipes da mesma localidade e dos demais habitantes da região do Vale do Itajaí. 6. Caberá ao Estado de Santa Catarina a retomada e a manutenção do diálogo com as lideranças da Comunidade Indígena, assegurando, inclusive, sempre que possível, na busca da solução a ser dialogicamente construída, a participação e a oitiva do Ministério dos Povos Indígenas. 7. Defiro o requerimento do Ministério Público Federal concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a Comunidade Indígena apresente eventuais solicitações adicionais

surgidas em razão dos efeitos práticos sentidos com o fechamento das comportas, apresentando-as para apreciação do Juízo. 8. Saem intimados os presentes.

É o relatório.

2. Da legitimidade da APIB para ingresso como litisconsorte necessária

Preliminarmente, é fundamental assentar a legitimidade ativa da **Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB,** que representa os povos indígenas de todo o país. Essa legitimidade se assenta em duas razões.

Em primeiro lugar, trata-se de uma **entidade de classe de âmbito nacional**, na forma do art. 103, inciso IX, CF/88, c/c art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/1999. A interpretação deste dispositivo, como vem sendo consolidada pelo Plenário do STF em relação à matéria e à entidade ora proponente no âmbito da ADPF 709, da ADPF 991 e da ADI 6622, deve reconhecer as entidades nacionais que representam outros segmentos da sociedade, notadamente grupos vulneráveis e minorias.

Em segundo lugar, a legitimidade da entidade deriva de interpretação conjugada do **art. 103, inciso IX, CF/88**, com o disposto no **art. 232 da Constituição**, segundo o qual "os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo". Afinal, seria profundamente ilegítimo e antidemocrático negar à organização nacional dos povos indígenas a possibilidade de defender, perante a Suprema Corte do país, os direitos fundamentais das próprias populações indígenas, **especialmente quando se discute o seu direito de não serem exterminadas**.

A APIB é a organização que representa nacionalmente os povos indígenas. Trata-se, aliás, da única entidade nacional de representação dos povos indígenas brasileiros. De acordo com o art. 4º do seu regimento, ela é composta pelas seguintes organizações regionais: (i) Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME);[1] (ii) Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB);[2] (iii) Articulação dos Povos Indígenas do Sul (ARPINSUL);[3] (iv) Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (ARPIN-SUDESTE);[4] (v) Conselho do Povo Terena;[5] (vi) Aty Guasu Kaiowá Guarani;[6] e (vii) Comissão Guarani Yvyrupa[7]. Ela está presente em mais de nove unidades da federação brasileira, satisfazendo o requisito assentado pela jurisprudência sobre o *caráter nacional* da entidade.

Segundo seu regimento interno[8], a APIB foi criada em 2005 pelo Acampamento Terra Livre (ATL), mobilização nacional, realizada anualmente em Brasília, para tornar visível a situação dos direitos indígenas e reivindicar do Estado brasileiro o atendimento das demandas e reivindicações dos povos indígenas. A entidade tem por missão a *"promoção e defesa dos direitos indígenas, a partir da articulação e união entre os povos e organizações indígenas das distintas regiões do país"*.

Além de congregar as maiores organizações indígenas regionais de todas as partes do país, a APIB possui reconhecimento no campo internacional, tendo ocupado lugar de destaque na Organização das Nações Unidas (ONU), na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e no Parlamento Europeu,

---

[1] Composta por povos presentes nos Estados do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito Santo.

[2] Abrange povos dos Estados do Amazonas, do Acre, do Amapá, do Maranhão, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, de Roraima e do Tocantins.

[3] Representa povos localizados nos Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

[4] Organização que abrange povos dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

[5] Organização tradicional de Mato Grosso do Sul.

[6]. Localizada no Estado do Mato Grosso do Sul.

[7] Abrange povos dos Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, do Paraná, de Santa Catarina e do
Rio Grande do Sul.

[8] APIB. *Regimento Interno.* Disponível eletronicamente em: <http://apib.info/apib/>.

denunciando as violações dos direitos das comunidades indígenas e retrocessos sociais na política indigenista do país. Não faria sentido que não pudesse fazer o mesmo perante a Suprema Corte brasileira.

Como expressão e instrumento do regime democrático, compete à APIB dar voz aos povos indígenas em todos os âmbitos de vulnerabilidade, a fim de que seus anseios possam ser ouvidos e considerados no Judiciário – sendo, portanto, legitimada a propor a presente ADPF para a proteção de direitos difusos. Assim, há a clara função de democratização do acesso à Justiça, dando efetividade à terceira onda renovatória[9], bem como enriquecendo o diálogo jurídico.

O acesso dos diferentes grupos presentes na sociedade à jurisdição constitucional – especialmente os tradicionalmente excluídos – é essencial para que esta possa se converter num campo de efetiva concretização dos direitos fundamentais. Trata-se de dar voz a quem não é ouvido. Na Colômbia, a qual possui um tribunal constitucional que é referência em matéria de direitos humanos para todo o mundo, o fácil acesso à Corte[10] é apontado como uma das causas do êxito da instituição em se converter em um espaço privilegiado para lutas emancipatórias[11].

Na Índia, cuja Suprema Corte também tem atuação destacada em matéria da proteção dos direitos fundamentais, foi necessária uma construção jurisprudencial extremamente ousada para viabilizar a defesa dos direitos dos grupos mais vulneráveis. O Tribunal, sem base legal expressa, flexibilizou ao extremo as regras sobre legitimidade ativa (*locus standi*) e formalidades processuais para permitir que qualquer pessoa ou entidade lhe peticionasse na defesa de

---

[9] CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. *Acesso à Justiça.* Tradução Ellen Gracie. Porto Alegre: Fabris, 1988.

[10] Na Constituição da Colômbia de 1991, qualquer cidadão pode suscitar o controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos na Corte Constitucional, por meio da chamada *acción pública*, bem como buscar a proteção dos seus direitos fundamentais naquele tribunal, quando não houver outro meio eficaz para fazê-lo, por meio da *acción de tutela*.

[11] Cf. Manuel José Cepeda-Espinosa. "Judicial Activism in a Violent Context: The Origin, Role and Impact of the Colombian Constitutional Court". *Washington University of Global Studies Law Review*, vol. 03, 2004; e Rodrigo Uprimny Yepes. "A Judicialização da Política na Colômbia: Casos, Potencialidades e Riscos". *Sur – Revista Internacional de Direitos Humanos,* vol. 06, 2007.

interesses de terceiros, sem nem sequer a necessidade de representação por advogado, sempre que estivessem em jogo os direitos fundamentais de indivíduos ou grupos miseráveis, desprovidos de acesso à justiça[12].

No Brasil, o constituinte originário quis estender o acesso à jurisdição constitucional às entidades da sociedade civil, ao estabelecer o art. 103, inciso IX, da Lei Maior. Porém, sua orientação vinha sendo parcialmente frustrada pelo STF que, nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, adotou *"posição severa e restritiva na matéria"*[13], estabelecendo limitações à legitimidade ativa para as entidades de classe claramente discrepantes do espírito da Constituição. O *leading case* foi a ADI n° 42[14], julgada em 1992, em que a Corte assentou, por maioria, que entidade de classe é apenas a que reúne pessoas que exerçam a mesma atividade profissional ou econômica. Na ocasião, o voto vencido do Ministro Célio Borja já apontava para o equívoco dessa construção: *"a classe não é um numerus clausus de atividades ou interesses, identificados e classificados pelo Estado, como no corporativismo estadonovista; mas, para compatibilizar-se com uma Constituição que põe entre os objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre e solidária (art. 3º, I), deve a classe ou categoria ser espécie ou gênero que as pessoas elegem, a cada momento, como relevantes e para cuja defesa ou fomento se submetem à disciplina societária que melhor lhes pareça"*.

Não há qualquer razão legítima que justifique essa interpretação restritiva do texto constitucional. Ela não decorre da interpretação literal do preceito, pois a palavra "classe" é altamente vaga, comportando leituras muito mais generosas. Ela não se concilia com a interpretação teleológica da Constituição, pois, como se viu acima, frustra o objetivo do texto magno, que foi democratizar o acesso

[12] Esta linha jurisprudencial é identificada na Índia pelo rótulo de public interest litigation. Veja-se, a propósito, Menaku Guruswamy e Bipin Aspatwar. "Access to Justice in India: The Jurisprudence (and Self-Perception) of the Supreme Court. In: Daniel Bonilla Maldonado (Ed.). *Constitutionalism of the Global* South: The Activist Tribunals of India, Colombia and South Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 2013; S. P. Sathe. Judicial Activism in India. 2a ed., New Delhi: Oxford University Press, 2002, pp. 201-211.
[13] Luís Roberto Barroso. *O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro.* 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 145.
[14] STF. ADI n° 42, Tribunal Pleno, Rel. Min. Paulo Brossard, julg. 24/09/1992.

ao controle concentrado de constitucionalidade. A exegese não se ajusta ao elemento histórico, pois não corresponde à intenção do constituinte originário de abrir as portas da jurisdição constitucional para a sociedade[15]. Pior, ela colide frontalmente com a interpretação sistemática da Carta, afrontando o postulado de unidade da Constituição.

Com efeito, inexiste na Constituição de 88 uma priorização dos direitos e interesses ligados às categorias econômicas e profissionais, em detrimento dos demais. Pelo contrário, a Constituição revelou preocupação no mínimo equivalente com a garantia de outros direitos fundamentais. Ela cuidou, ademais, da proteção de minorias e grupos vulneráveis, como povos indígenas, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, afrodescendentes, quilombolas, mulheres etc. – grupos que têm interesses comuns, que não se reduzem à profissão ou à economia. A Carta de 88 se abriu, por outro lado, para múltiplas demandas por justiça, não só no campo da distribuição, como também na esfera do reconhecimento[16], por admitir que as ofensas à dignidade humana também decorrem de práticas estigmatizadoras e opressivas, que desdenham os grupos portadores de identidades não hegemônicas. Tais questões não têm, via de regra, qualquer ligação com categorias profissionais ou econômicas específicas.

Assim, não há porque permitir o acesso à jurisdição constitucional para atores que encarnam os interesses das profissões e categorias econômicas, mas

---

[15] Nesse sentido, Plínio de Arruda Sampaio, relator da subcomissão da Constituinte responsável pela organização do Judiciário e do Ministério Público afirmou que: "[...] havia [...] um clima que era importante dar peso à sociedade civil. No Brasil, o partido só ainda era uma coisa muito limitada. A ideia era não subordinar isso [o acesso] a interesses, deixar o mais possível aberto [...]" (Ernani Carvalho. *Política Constitucional no Brasil: a ampliação dos legitimados ativos na Constituinte de 1988*. Revista da EMARF, Cadernos Temáticos, 2010, p. 97-118). Na mesma linha, Andrei Koerner e Lígia Barros de Freitas. *O Supremo na Constituinte e a Constituinte no Supremo*. Lua Nova, vol. 88, 2013, p. 141-184.

[16] Sobre o reconhecimento como dimensão da justiça, veja-se Nancy Fraser. "Redistribuição, reconhecimento e participação: por uma concepção integral de justiça". In: Daniel Sarmento, Daniela Ikawa e Flávia Piovesan (Coord.). *Igualdade, Diferença e Direitos Humanos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010; Axel Honneth. *Luta por Reconhecimento*: a gramática moral dos conflitos sociais. Trad. Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003. Destaque-se que a importância do reconhecimento no campo dos direitos fundamentais vem sendo reconhecida pelo STF em várias decisões, como na ADPF n° 186, que trata das cotas raciais em universidades, e na ADPF n° 132 e ADI n° 142, que trataram da união homoafetiva.

não permití-lo aos que corporificam outros direitos e interesses, que são valorados, no mínimo, com o mesmo peso pela ordem jurídica brasileira**. Essa assimetria no campo das garantias jurisdicionais é absolutamente injustificada**. Em boa hora, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, nos termos do art. 232 da Constituição da República., como se infere de decisões adotadas nos autos da ADPF 709 e da ADPF 991, conforme segue:

> DIREITOS FUNDAMENTAIS. POVOS INDÍGENAS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE FACE À PANDEMIA DA COVID-19. CAUTELARES PARCIALMENTE DEFERIDAS. 1. Ação que tem por objeto falhas e omissões do Poder Público no combate à pandemia da COVID-19 entre os Povos Indígenas, com alto risco de contágio e mesmo de extermínio de etnias. **2. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB possui legitimidade ativa para propor ação direta perante o Supremo Tribunal Federal e, bem assim, os partidos políticos que assinam a petição inicial. Premissas da decisão** 3. Os Povos Indígenas são especialmente vulneráveis a doenças infectocontagiosas, para as quais apresentam baixa imunidade e taxa de mortalidade superior à média nacional. Há indícios de expansão acelerada do contágio da COVID-19 entre seus membros e alegação de insuficiência das ações promovidas pela União para sua contenção. 4. Os Povos Indígenas têm o direito de participar da formulação e execução das ações de saúde que lhes são destinadas. Trata-se de direito assegurado pela Constituição de 1988 e pela Convenção 169 da OIT, que é norma interna no Brasil. 5. A análise aqui desenvolvida observou três diretrizes: (i) os princípios da precaução e da prevenção, no que respeita à proteção à vida e à saúde; (ii) a necessidade de diálogo institucional entre o Judiciário e o Poder Executivo, em matéria de políticas públicas decorrentes da Constituição; e (iii) a imprescindibilidade de diálogo intercultural, em toda questão que envolva os direitos de povos indígenas. Pedidos formulados 6. Na ação são formulados pedidos específicos em relação aos povos indígenas em isolamento ou de contato recente, bem como pedidos que se destinam aos povos indígenas em geral. Tais pretensões incluem a criação de barreiras sanitárias, a instalação de sala de situação, a retirada de invasores das terras indígenas, o acesso de todos os indígenas ao Subsistema Indígena de Saúde e a elaboração de plano para enfrentamento e monitoramento da COVID-19. 7. Todos os pedidos são relevantes e pertinentes.

Infelizmente, nem todos podem ser integralmente acolhidos no âmbito precário de uma decisão cautelar e, mais que tudo, nem todos podem ser satisfeitos por simples ato de vontade, caneta e tinta. Exigem, ao revés, planejamento adequado e diálogo institucional entre os Poderes. Decisão cautelar Quanto aos pedidos dos povos indígenas em isolamento e de contato recente 8. Determinação de criação de barreiras sanitárias, conforme plano a ser apresentado pela União, ouvidos os membros da Sala de Situação, no prazo de 10 dias, contados da ciência desta decisão. 9. Determinação de instalação da Sala de Situação, como previsto em norma vigente, para gestão de ações de combate à pandemia quanto aos povos indígenas em isolamento e de contato recente, com participação de representantes das comunidades indígenas, da Procuradoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União, observados os prazos e especificações detalhados na decisão. Quanto aos povos indígenas em geral 10. A retirada de invasores das terras indígenas é medida imperativa e imprescindível. Todavia, não se trata de questão nova e associada à pandemia da COVID-19. A remoção de dezenas de milhares de pessoas deve considerar: a) o risco de conflitos; e b) a necessidade de ingresso nas terras indígenas de forças policiais e militares, agravando o perigo de contaminação. Assim sendo, sem prejuízo do dever da União de equacionar o problema e desenvolver um plano de desintrusão, fica determinado, por ora, que seja incluído no Plano de Enfrentamento e Monitoramento da COVID-19 para os Povos Indígenas, referido adiante, medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas ou providência alternativa apta a evitar o contato. 11. Determinação de que os serviços do Subsistema Indígena de Saúde sejam acessíveis a todos os indígenas aldeados, independentemente de suas terra estarem ou não homologadas. Quanto aos não aldeados, por ora, a utilização do Subsistema de Saúde Indígena se dará somente na falta de disponibilidade do SUS geral. 12. Determinação de elaboração e monitoramento de um Plano de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos Indígenas Brasileiros, de comum acordo, pela União e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, com a participação das comunidades indígenas, observados os prazos e condições especificados na decisão. 13. Voto pela ratificação da cautelar parcialmente deferida.

DIREITO CONSTITUCIONAL. REFERENDO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO ESTRUTURAL DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO PONTUAL DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO. PLANO DE AÇÃO PARA A

> REGULARIZAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS COM PRESENÇA DE POVOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO. CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONSULTA PREVISTA NA CONVENÇÃO 169. RECONHECIMENTO DA FORMA ISOLADA DE VIVER COMO LIVRE AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS. **1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, nos termos do art. 232 da Constituição da República.** 2. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é meio processualmente adequado ao litígio de feição estrutural. Precedentes. 3. A superação do paradigma assimilacionista para um de respeito à pluralidade e ao seu modo de vida traduz-se na política do não contato, de forma a respeitar a escolha das comunidades em permanecer distantes do modo de vida da sociedade envolvente, de manter a integridade das terras necessárias à sua subsistência e ao desenvolvimento de sua expressão cultural, e também de evitar a disseminação de patógenos que possam levar à propagação de doenças e ao extermínio de um grande número de indígenas, diante da evidente vulnerabilidade imunológica que possuem. 4. A omissão comprovada da Administração Pública na adoção de medidas para a proteção da vida e da integridades física dos territórios de povos indígenas isolados e de recente contato, somado ao riscos inerentes à abertura de suas terras à exploração comercial, justifica a ordem para que a elaboração de um Plano de Ação para o saneamento dessas irregularidades. 5. Medida cautelar referendada. (ADPF 991,Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 08/08/2023, Publicação: 02/10/2023

Ainda que não se queira adotar, em todos os casos, essa leitura da expressão "entidade de classe", contida no art. 103, inciso IX, da CF/88, no mínimo se justifica a abertura da categoria em relação às organizações nacionais de representação dos povos indígenas, à luz de interpretação harmonizada com o disposto no art. 232, CF/88.

Tal preceito – o art. 232 – se inscreve no modelo não paternalista com que a Constituição de 88 tratou os povos indígenas. Pretendeu o constituinte empoderá-los, rompendo com o paradigma pretérito calcado no paternalismo e na tutela. Por isso, os povos indígenas e suas organizações devem poder defender seus direitos e interesses em todos os espaços jurisdicionais, sem depender, para tanto, da

intermediação necessária de instituições "dos brancos", como a FUNAI, os partidos políticos, o Ministério Público Federal, etc. Cuida-se de tratar os povos indígenas como protagonistas de suas lutas, e não como meros beneficiários da ação, ainda que benevolente, de terceiros. Trata-se de respeitar o nosso *lugar de fala*.

Nessa perspectiva, sendo a jurisdição constitucional um *locus* privilegiado para a proteção de direitos fundamentais – especialmente direitos de minorias –, não faz sentido adotar interpretação que exclua as organizações nacionais dos povos indígenas do campo dos legitimados ativos para propositura de ações diretas na jurisdição constitucional do STF, relativas à defesa dos direitos dos próprios povos indígenas. A interpretação sistemática dos arts. 103, inciso IX, e 232 da CF/88 impõe, no mínimo, que se reconheça às organizações nacionais indígenas o direito de defenderem na jurisdição constitucional brasileira o direito desses povos originários.

É certo que, como ocorre com praticamente todas as organizações indígenas, a APIB não se encontra formalmente constituída como pessoa jurídica, nos moldes da "lei dos brancos". Nada obstante, não há dúvida de que a entidade congrega e representa os povos indígenas do Brasil. Como organização indígena, a APIB se rege por costumes e tradições também indígenas, afigurando-se inexigível a sua formalização como pessoa jurídica para que possa defender em juízo, inclusive perante esta Suprema Corte, os direitos dos povos indígenas brasileiros. Pretender o contrário seria negar o espírito do art. 232 da Constituição, que abriu as portas do sistema de justiça às comunidades e organizações indígenas, sem submetê-las à ilegítima exigência de prévia regularização, de acordo com o formalismo jurídico da sociedade envolvente. Destaque-se, neste particular, que no RE nº 1.017.365, em que se discute, em regime de repercussão geral, a questão do chamado "marco temporal" para demarcação de terras indígenas, a APIB foi admitida como *amicus curiae* por esta

Suprema Corte, assim como diversas outras comunidades e organizações indígenas também desprovidas de constituição formal como pessoas jurídicas (RE n° 1.017.365, Decisão Monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21/05/2020). Além de ter sido admitida como Amicus Curiae também na ADPF 760, na ADI 6553, na ADI 6672, na ADI 6852.

Frise-se que o Plenário do STF já reconheceu a legitimidade da Associação Autora na oportunidade do julgamento do Referendo em Medida Cautelar na ADPF 709 (DOU 07.10.2020), na qual se busca a correção da insuficiência ou mesmo inexistência de políticas públicas adequadas à garantia dos direitos à vida, saúde, dignidade e manutenção da vivência em seus próprios territórios aos indígenas, acometidos de maneira agressiva pela pandemia ocasionada pela COVID-19, com o risco de verdadeiro etnocídio em diversas Terras Indígenas.

Como bem apontou o i. Ministro Luís Roberto Barroso, Relator daquela ação, a interpretação restritiva da legitimidade ativa para ajuizamento de ações de controle concentrado *"acabou reduzindo as oportunidades de atuação do Tribunal na proteção a direitos fundamentais, já que não reconheceu às associações defensoras de direitos humanos (que não constituem representação de categoria profissional ou econômica) a possibilidade de acessá-lo diretamente, em sede concentrada"*.

Portanto, o Tribunal possibilitou que também as associações como a Autora, representativa de um grupo minoritário que pretende a defesa de seus direitos fundamentais, possam atuar como legitimada ativa para a propositura de ações de controle concentrado.

Mais recentemente, nos autos da ADPF 991, o Ministro Edson Fachin, nos termos do entendimento firmado nos autos da ADPF 991, corroborou a existência de legitimidade ativa da APIB para ingresso em ações judiciais, sob a lição de que não se mostra razoável glosar sua capacidade para figurar como parte legítima para

ingressar com o presente feito, especialmente em se considerando que a Constituição de 1988 representa, em verdade, a superação do paradigma tutelar relativo aos indígenas, alçando-os à cidadania plena. Assim, a garantia da representação judicial dos mais diversos povos indígenas por meio de um entidade de âmbito nacional, constituída pelos próprios índios, com atribuições de defesa de seus direitos, concretiza essa transição paradigmática e deve, pois, ser plenamente acolhida por esta Corte.

Do mesmo modo, destaca-se a importância dos precedentes como a ADPF 709, ADPF 991 e a ADI 6622, que já reconheceram a legitimidade da APIB para propor/atuar em ações que remetam à proteção dos povos indígenas. Assim, deve-se reconhecer a legitimidade ativa da APIB para o ingresso como litisconsorte necessário na presente ação.

Subsidiariamente, o art. 113 do Código de Processo Civil (CPC) determina que duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Continuamente, o art. 114 do Código de Processo Civil determina que o **litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.**

Nesta senda, a jurisprudência do STJ (REsp 1.058.223/MG) é firme no sentido de que o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, de forma a caber ao juiz a determinação, de ofício ou a requerimento de qualquer uma das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo.

A presente ação é Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença contra a União e o Estado de Santa Catarina em razão da condenação dos entes públicos à realização de diversos serviços de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente.

Dessa forma, o ingresso da comunidade no feito na modalidade de litisconsorte necessário é reluzente, sendo que, uma decisão de mérito que mantenha a liminar deferida pelo juízo é de incidência direta no direito territorial da comunidade indígena, bem como, uma decisão desfavorável também possui caráter de afetação direta ao direito territorial dos indígenas que lá habitam.

O ingresso da comunidade em juízo é pacífico vez que o art. 231 e 232 dispõe essa garantia jurídica aos indígenas, suas comunidades ou organizações de possuírem legitimidade para vir a juízo na defesa de seus interesses, além do entendimento jurisprudencial mantido pelo STF, conforme exaustivamente acima apresentado.

Nestes termos é o **Parecer ofertado pelo Emérito Professor da USP, José Afonso da Silva**[17], para integrar o agravo já citado na ACO 2323, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. Diz o Eminente jurista:

> **E se chama isso de interesse apenas mediato ou reflexo? O prejuízo é imediato e direto, logo o direito ou interesse em evita-lo é também imediato e direto.** Ora, o art. 232 da Constituição, ao conferir legitimidade aos índios, suas comunidades e organizações para ingressar em juízo na defesa de deus direitos ou interesses, conferiu correlativamente todos os poderes para que essa defesa seja real e eficaz. **Se isso precisa ter uma qualificação processual, só pode ser a de litisconsórcio passivo**. Fora disso é desrespeitar a regra
>
> constitucional. Quer dizer, **a decisão do Douto Relator admitindo apenas a assistência simples e o desentranhamento da contestação e**

[17] Parecer do Professor José Afonso da Silva, em consulta feita pela Comunidade Indígena Guarani de Morro dos Cavalos, elaborado para a ACO 2323 de relatoria do Ministro Alexandre de Morai, datado de 30.01.2019.

> **demais peças processuais da comunidade contraria o dispositivo constitucional. É, pois, inconstitucional,** como todas as vênias2. (g.n.).

Sobre o tema, além dos entendimentos já acima mencionados, são os seguintes os precedentes mais recentes quanto ao litisconsórcio necessário, somente no STF: ACO 1100/SC, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe Nr. 39 do dia 02/03/2016; MS 33.922, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/2/2016; RE nº 1017365, Rel. Min EDSON FACHIN, DJe 13.05.2019; MS 28.541, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 05/11/2018; MS 28.574, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 18/12/2018; MS 34.250, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2017; e, ACO 1522. Re. Min. GILMAR MENDES, Dje 04.05.2018; AC 2541, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 06.06.2017; e, ACO 2323, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAIS, DJe 18.02.2019; AR 2756, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE nº 195, divulgado em 06/09/2019; AR 2750, Rel. Min. ROSA WEBER, DJE nº 218, divulgado em 07/10/2019; AR 2761, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJE nº 243, divulgado em 06/11/2019.

Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a "*questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena*", no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1017365, da relatoria do Ministro Edson Fachin. E neste processo de repercussão geral, o Ministro Relator acolheu o pedido da comunidade indígena Xokleng no feito, na qualidade de litisconsorte passiva necessária (DJE nº 98, divulgado em 10/05/2019).

Essa política de negação de direitos territoriais, tanto em passado não muito distante, como nos dias atuais, a intenção do Estado é de assimilar o índio à comunhão nacional, planificar o que não se pode homogeneizar. É tornar a diferença, a multiculturalidade, numa massa uniforme e desprovida de direitos.

Por outra banda, isso demonstra o descaso do Estado brasileiro com os povos indígenas, já que o indígena não deixa de ser indígena por não ter terra demarcada, como bem ficou definido no caso Raposa Serra do Sol, acima transcrito – pois seu direito é declarado, anterior a qualquer outro e cabe ao Estado fazer valer o mandamento constitucional.

Para demonstrar a necessidade de proteção e de garantia territorial a todos os grupos étnicos, nos termos do que determinou o Constituinte Originário, ao replicar a tese do indigenato, temos que:

> Segundo Sarmento (2013, p. 13), "a melhor interpretação da Constituição, sem sombra de dúvidas, é a que qualifica o direito do art. 231 da Constituição como cláusula pétrea", tendo em vista o inequívoco propósito do constituinte de garantir a máxima efetividade aos direitos fundamentais indígenas. Dessa forma, a instituição de um marco temporal como condição para a sua garantia contraria de modo expresso o texto constitucional, praticamente ferindo de morte o conceito de direito originário e congênito. A Constituição, de diversas formas, preocupou-se em não legitimar os esbulhos ocorridos no passado, e isso não se pode negar.
>
> (...)
>
> Essa confusão ocorre, segundo a doutrina, em razão do equívoco cometido pela tese do marco temporal, que considera a ocupação indígena de acordo com os parâmetros relacionados à posse do direito civil, quando a Constituição trata do indigenato, instituto diverso. Nos termos do parecer elaborado por Silva (2016, p. 17), o conflito nas terras indígenas "não é uma disputa de natureza possessória, porque os índios, como observado, não têm uma posse nesse sentido de direito privado". São, como já se afirmou, direitos originários e congênitos, que não se subordinam a uma cadeia dominial, e a Constituição de 1988 deixou isso evidente. "Não se pode exigir da comunidade indígena que ostente os títulos da terra ou que demonstre a ocupação efetiva e ininterrupta. Os direitos dos índios às suas terras precedem a qualquer outro" (Silva, 2004, p. 145)[18].

Com efeito, não resta outra alternativa, por ser extremamente necessária a participação direta da comunidade indígena, para que seus interesses sejam

[18] Juzinskas e Ayres, g. 29.

resguardados e que assim se possa garantir o acesso à justiça pela Comunidade Indígena Laklãnõ Xokleng, motivo pelo qual requer o ingresso Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) nos autos como litisconsorte necessário.

DOS REQUERIMENTOS

Em razão do exposto, requer-se:

I. Que seja deferido o pedido para conceder à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) o ingresso nos autos como litisconsorte necessário.

II. Requer ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados **Maurício Serpa França (OAB/MS 24.060), Andressa Carvalho Santos (OAB/BA 75.890), Giovanna Dutra Silva Valentim (OAB/SP 485.585) e Iorrannis Luiz Moreira da Silva (OAB/MS 27.100).**

Termos em que se pede e espera deferimento.

Brasília/DF, 09 de outubro de 2023.

Mauricio Serpa França
Coordenador Jurídico da APIB
OAB/MS 24.060

Iorrannis Luiz Moreira da Silva
Secretário Jurídico da APIB
OAB/MS 27.100